

MUHAMAD ZAIRI BIN ZULKEFLE
lwn
NORHAIRIYAH BINTI SHAHARUDIN

[Mahkamah Rayuan Syariah Shah Alam Di Selangor, YAA Tn. Hj. Mohd Amran Bin Hj. Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Hj. Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel), YA Tn Hj. Othman bin Ibrahim (Panel), Pada 11 September 2020 bersamaan 23 Muharram 1441H]

[Kes Mal (Semakan) No. 10000-003-0066-2020]

[Permohonan Semakan di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Pemohon

Puan Noorafizah binti Abdul Aziz daripada Tetuan Noorafizah Abdul Aziz Associates

Peguam Responden

Muhamad Hafiz bin Mohsin daripada Jabatan Bantuan Guaman, Selangor

PERMOHONAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon pada 23/7/2020 bagi menyemak keputusan / perintah yang telah diputuskan oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam pada 29/6/2020 di dalam kes no. 10200-038-0072-2020.

[2] Pemohon memfailkan permohonan semakan ini adalah untuk mendapatkan suatu perintah sepertimana berikut –

- (a) Bahawa suatu semakan dibuat terhadap arahan dan/atau perintah yang dibuat oleh Hakim Bicara bertarikh 29/6/2020 melalui Permohonan No : 10200-038-0072-2020;
- (b) Bahawa Mahkamah Rayuan Syariah Selangor membatalkan perintah tersaebut dan mahkamah perlu mengekalkan statusquo yang mana anak-anak telah lazim tinggal dengan Pemohon sejak lahir dan bersekolah di kawasan yang berdekatan dengan tempat tinggal anak-anak tersebut selari dengan peruntukan seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003;
- (c) Dan/atau Mahkamah memanggil anak-anak tersebut untuk ditemubual dan meyatakan pilihan penjaga bagi anak-anak tersebut berdasarkan kepada peruntukan seksyen 85 (2) Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (negeri Selangor) 2003;
- (d) Apa-apa perintah atau relif lain yang suai dan manfaat yang difikirkan patut dan wajar oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

[3] Permohonan semakan ini difailkan bersama-sama Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan bertarikh 23/7/2020. Alasan Pemohon bagi permohonan semakan ini adalah diringkaskan sebagaimana berikut :-

- i. Mahkamah Bicara telah tersilap dengan terus membuat keputusan yang didengari sahaja dan/atau perintah tanpa mengikut tatacara Mal yang diperuntukkan.

- ii. Mahkamah perlu mengambil kira status quo anak-anak tersebut.
- iii. Perintah yang diperolehi tersebut tidak memetingkan kebajikan dan kemaslahatan anak-anak tersebut serta sedikit sebanyak telah mengganggu emosi anak-anak tersebut.

FAKTA KES

[4] Pemohon dan Responden telah bernikah pada 14/12/2008 dan telah bercerai pada 6/8/2019. Hasil perkahwinan, mereka dikurniakan dua (2) orang iaitu seorang anak perempuan dan seorang anak lelaki.

[5] Kes di Mahkamah Tinggi Syariah tersebut adalah mengenai permohonan interim hak jagaan anak secara *inter-parte* yang telah difailkan oleh Responden. Permohonan tersebut telah diluluskan dan Mahkamah Tinggi Syariah telah memerintahkan seperti berikut:-

- a. Mahkamah meluluskan permohonan Pemohon sebagaimana seksyen 201 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
- b. Mahkamah memerintahkan bahawa hak penjagaan sementara bagi anak-anak yang bernama Nuratiqah Najwa binti Muhamad Zairi [No. Mykid : 090824-10-1528] dan Muhamad Raihan Danial bin Muhamad Zairi [No. Mykid : 120618-10-2655] diberikan kepada Pemohon(ibu).

- c. Responden (bapa) diberikan hak bermalam dengan anak-anak tersebut pada minggu kedua dan keempat dengan mengambil anak-anak tersebut di tempat tinggal anak-anak tersebut bermula jam 8.00 malam hari jumaat dan memulangkan semula anak-anak tersebut kepada Pemohon sebelum atau pada jam 6.00 petang hari Ahad.
- d. Mahkamah memerintahkan pihak Polis Diraja Malaysia (PDRM) dan/atau pihak berkuasa yang berkaitan untuk memastikan perintah ini dapat dilaksanakan dengan baik.
- e. Perintah sementara ini hendaklah berkuatkuasa serta merta sehingga ada perintah lain dikeluarkan atau sehingga kes induk hadanah saman no : 10207-028-0529-2019 diputuskan.

[6] Pemohon tidak berpuashati dengan keputusan tersebut dan telah memfailkan semakan ini.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[7] Sukacita kami tegaskan di sini bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[8] Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003. Di samping itu juga, Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti kes *Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah*, JH 36 (2), kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes *Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, Kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra*, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

[9] Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[10] Bagi melaksanakan semakan ini, kami telah memanggil dan menyemak rekod kes Permohonan No. : 10200-038-0072-2020. Penelitian terhadap fail atau rekod kes tersebut sangat penting kerana proses semakan ialah untuk mengenalpasti apakah adanya apa-apa kecacatan sepanjang perbicaraan atau

kecacatan terhadap mana-mana perintah sama ada kecacatan dari segi undang-undang atau kekhilafan Hukum Syarak.

[11] Kami dapati bahawa kes tersebut telahpun selesai dan diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam Selangor, di mana YA Hakim Bicara telah memutuskan perintah sepertimana perenggan 5 (a-e). Kedua-dua pihak telah diwakili Peguam Syarie masing-masing semasa prosiding kes tersebut. Anak yang menjadi isu di dalam kes ini iaitu Nuratiqah Najwa binti Muhamad Zairi berumur 11 tahun dan Muhamad Raihan Danial bin Muhamad Zairi berumur 8 tahun.

[12] Pada sesi sebutan pada 29/6/2020, Peguam Syarie Pemohon (Responden) telah meminta satu tarikh untuk membolehkannya memfailkan Afidavit Balasan manakala Peguam Syarie Responden (Pemohon) telah meminta kebenaran kepada Mahkamah supaya menetapkan tarikh sebutan yang berikutnya untuk memanggil anak-anak tersebut dibawa ke mahkamah untk ditemubual. Walau bagaimanapun, YA Hakim Bicara telah serta merta memberikan keputusan dan/atau perintah interim inter parte tersebut. Mahkamah juga didapati telah YA Hakim Bicara tidak memberi peluang kepada Peguam Syarie kedua-dua pihak untuk membuat hujah penggulangan masing-masing.

[13] Bagi isu ini, kami kemukakan pandangan Panel Rayuan Syariah Negeri Melaka di dalam kes *Nur Adillah Binti Ya'akop lwn. Ahmad Hafiszan Bin Md Othman, Kes Mal (Semakan) No. 04000-003-0006-2019 [tidak dilaporkan]* yang diputuskan pada 5 Julai 2019 menegaskan bahawa :-

“ Berdasarkan semakan yang telah dijalankan kami berpuas hati bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf kerana tidak memberi peluang sewajarnya kepada Pemohon dan Peguam Syarie untuk meneliti Afidavit Jawapan serta membuat persediaan bagi tujuan penghujahan. Ini

menyebabkan terdapat kekurangan dari segi hujah lisan yang telah dikemukakan oleh Pemohon.”

[14] Secara umumnya kami ingin menyatakan bahawa matlamat institusi kehakiman syariah ialah untuk menegakkan keadilan. Ianya dapat difahami berdasarkan firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa’ ayat 58 :



﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾

Maksudnya : Sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya), dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, (Allah menyuruh) kamu menghukum dengan adil.

[15] Dalam melaksanakan keadilan dan membuat keputusan Rasulullah SWT telah memberi panduan agar seseorang Hakim dalam melaksanakan perbicaraan, sebelum membuat keputusan hendaklah mempunyai pengetahuan yang cukup tentang kedua-dua belah pihak yang bertikai. Asas terhadap perkara ini adalah sepertimana yang dinyatakan melalui hadis yang boleh dirujuk dalam kitab *Nailu Authar*, Jilid 8, Cetakan Dar Al-Hadith iaitu –

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "يا علي إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء"

Maksudnya : Bahawa Rasulullah s.a.w bersabda : “ Wahai Ali! Apabila berada di hadapan kamu dua orang yang bertelingkah, maka jangan kamu menghakimi di antara keduanya sehinggalah kamu mendengar dari pihak yang lain sepertimana kamu mendengar dari pihak yang pertama. Sekiranya kamu lakukan

demikian, nescaya akan jelaslah penghakiman”-(Riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi)

[16] Malah, penekanan yang sama turut diberikan oleh Khalifah Agung Kedua tersebut kepada Muaz bin Jabal r.a berkenaan kepentingan seseorang hakim memahami masalah yang dipertikaikan dengan memberi peluang kepada pihak-pihak membentangkan kes dan hujahnya, ***“Hakimilah sesuatu apabila engkau memahaminya, dan laksanakanlah apabila engkau menghakiminya.”***

فاقض إذا فهمت، وأنفذ إذا قضيت

[17] YA Hakim Bicara seharusnya berpegang kepada prinsip keadilan yang mengatakan *“Justice rushed is justice crushed”*, dengan tidak terburu-buru atau gopoh dalam mengendalikan kes atau memberikan keputusannya. Tindakan gopoh Hakim bicara dalam mengendalikan kes juga boleh menyebabkan ketidakadilan kepada pihak-pihak dalam sesuatu tindakan. Maksud kami di sini, ianya tidaklah bererti bahawa mahkamah boleh berlengah-lengah untuk menyelesaikan kes, kerana prinsip keadilan juga menyatakan *“Justice delayed is justice denied”*

[18] Bagi kes ini juga, kami dapati bahawa umur anak-anak yang menjadi isu pertikaian di dalam kes tersebut telah mencapai umur mumaiyyiz sepertimana peruntukan seksyen 85 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 [EUUKIS 2003] yang menyatakan –

(1) Hak hadinah bagi menjaga seseorang kanak-kanak adalah tamat setelah kanak-kanak itu mencapai umur tujuh tahun, jika kanak-kanak itu lelaki, dan umur sembilan tahun, jika kanak-kanak itu perempuan, tetapi Mahkamah boleh, atas permohonan hadinah, membenarkan dia menjaga kanak-kanak itu sehingga kanak-kanak itu mencapai umur sembilan tahun,

jika kanak-kanak itu lelaki, dan umur sebelas tahun, jika kanak-kanak itu perempuan.

- (2) *Setelah tamatnya hak hadhanah, penjagaan turun kepada bapa, dan jika kanak-kanak itu telah mencapai umur kecerdikan (mumaiyyiz), maka kanak-kanak itu adalah berhak untuk memilih untuk tinggal dengan sama ada ibu atau bapanya, melainkan jika Mahkamah memerintahkan selainnya.*

[19] Apabila suatu permohonan untuk mendapat perintah interim hadhanah secara inter-parte berdasarkan peruntukan seksyen 201 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 dipohon, maka ia juga perlu merujuk kepada peruntukan asal berkaitan dengan *hadhanah* berdasarkan seksyen 82 dan/atau 85 EUUKIS 2003.

[20] Berdasarkan subseksyen 85 (2) EUUKIS 2003, anak-anak tersebut telah melepasi tempoh jagaan (*hadhanah*) dan anak-anak tersebut sewajarnya diberi hak untuk membuat pilihan untuk tinggal dan bermalam kerana telah melepasi kewajipan *hadhanah*. Pendekatan peruntukan subseksyen 85 (2) EUUKIS 2003 untuk mendengar pendapat dan juga pemilihan anak-anak tersebut ini adalah berasaskan kepada alasan berikut -

قال الشافعي : فإذا افترق الأبوان وهما في قرية واحدة فالأم أحق بولدها ما لم تتزوج وماكانوا صغارا فإذا بلغ أحدهم سبعا أو ثمانا سنين وهو يعقل خير بين أبيه وأمه وكان عند أيهما اختار

Maksudnya : As-Shafie berkata: “Apabila berpisah kedua ibu bapa dan kedua-duanya berada dalam satu qariah maka ibu adalah lebih berhak terhadap anaknya selama ia belum berkahwin lain dan semasa anak-anak itu masih kecil. Apabila genap umur mereka

tujuh tahun atau lapan tahun dan ia sempurna akal ia disuruh pilih di antara bapa dan ibunya dan ia akan bersama dengan siapa yang dipilih.”(Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris, Al-Umm, Juzu’ 5, hlm. 99)”

[21] Menurut kitab “الخضانة وأثرها في تنمية سلوك الأطفال في الفقه الإسلامي” karangan Prof. Dr. Abdul Mutthalib Abdul Razzak Hamdan seorang Pensyarah di Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Al-Azhar Mesir, hlm. 73, menukilkan pandangan ulama As-Syafieyyah daripada kitab *Mughni Al-Muhtaj, Nihayah Al-Muhtaj* dan *Hasyiah Al-Jamal* seperti katanya -

فَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ : يَخِيرُ الْمُحَضُّونَ إِذَا مِيزَ ، وَالتَّمْيِيزُ أَنْ يَسْتَقِلَّ بِأُمُورِ نَفْسِهِ مِنَ الْأَكْلِ وَالشَّرْبِ وَنَحْوِهِ ، وَلَا عِبْرَةَ بِالْبُلُوغِ سَبْعَ سِنِينَ نَ فَلَوْ جَاوَزَ السَّبْعَ بِلَا تَمْيِيزٍ فَإِنَّهُ يَبْقَى عِنْدَ أُمِّهِ ، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى

Maksudnya : “Menurut ulama as-Syafieyyah ; kanak-kanak diberi pilihan untuk tinggal sama ada dengan ibunya atau dengan bapanya apabila ia sudah mumaiyyiz. Maksud Mumaiyyiz ialah kanak-kanak itu boleh melakukan perbuatan tersebut dengan sendirinya seperti makan, minum dan sebagainya, jika sekiranya umur kanak-kanak itu melebihi tujuh tahun tetapi tidak mumaiyyiz maka hak penjagaan kepada ibunya, yang sedemikian tidak ada beza di antara kanak-kanak itu lelaki atau perempuan”

[22] Apabila anak itu sudah mumaiyyiz, maka ia boleh membuat pilihan sama ada hendak tinggal dengan ibunya atau dengan bapanya, ini berdasarkan Hadis Rasulullah s.aw iaitu -

عن ابي هريرة رضى الله عنه قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني ، وقد سقاني من بئر أبي عتبة ، وقد نفعني ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إستهما عليه) فقال زوجها : من يحاقي في ولدي ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (هذا أبوك ، وهذه أمك ، فخذ بيد أيهما شئت) فأخذ بيد أمه ، فانطلقت به .

"Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a katanya; Telah datang seorang perempuan kepada Rasulullah s.aw seraya berkata: "Wahai Rasulullah s.aw sesungguhnya suamiku hendak membawa anakku bersamanya, sedangkan anakku telah menolongku mengambil air daripada telaga Abi 'Itabah (أبي عتبة) (iaitu sebuah telaga di Madinah Munawwarah) dan anakku banyak memberi faedah kepadaku daripada pertolongannya itu. Maka Sabda Rasulullah s.a.w; Hendaklah kamu berdua membuang undi tentang anak kamu, maka suaminya itu menjawab "Siapakah yang boleh menghalang hakku tentang anakku ini." Lalu Baginda Rasulullah s.a.w berkata kepada anak itu agar membuat pilihan sama ada ingin tinggal dengan ibunya atau mengikut bapanya dengan sabdanya; "Ini bapa kamu dan ini juga ibu kamu, maka pilihlah siapa di antara kedua-duanya yang engkau suka tinggal bersama". Maka anak itu pun memilih ibunya dengan memegang tangan ibunya itu, lalu perempuan itu pun membawa anaknya itu pulang bersamanya" (Riwayat Abu Daud 2/ 283 Kitab Al-Talaq).

[23] Menurut pandangan Imam Muhammad Bin Ismail Al-Yamani As-Shon'aani di dalam kitabnya *Subul As-Salam*, jilid 3, hlm. 228 -

فقد دل الحديث على أنه بعد إستغناء الصغير بنفسه ، يخير بين ابويه

"Hadis di atas menunjukkan bahawa kanak-kanak yang sudah boleh menguruskan dirinya dengan sendiri diberi pilihan untuk tinggal dengan salah seorang daripada kedua ibubapanya"

[24] Berdasarkan rujukan di atas, Mahkamah perlu melakukan ujian bagi menentukan sama ada anak-anak tersebut telah *tamyiz / mumaiyyiz* ataupun tidak.

Ujian yang dimaksudkan di dalam otoriti di atas memerlukan Mahkamah menemubual anak-anak tersebut dan mengetahui pilihan dan alasannya untuk memilih *hadhinah* atau *hadimnya*.

[25] Kami merujuk kepada kes **Noor Azrin Binti Abd Razak lwn Saiful Johari Bin Ahmad, Kes Semakan (No 10000-003- 0154-2018) pada 5 April 2019** [tidak dilaporkan] Hakim Rayuan Syariah Negeri Selangor memutuskan seperti berikut:-

“Bagi kes Permohonan No. : 10400-038-0351-2018, kami dapati bahawa YA Hakim Bicara tidak memanggil atau menemubual anak-anak tersebut yang telah melangkaui umur mumaiyyiz sebelum keputusan dibuat. YA Hakim Bicara juga di dalam penghakimannya tidak menjustifikasikan tindakan beliau yang tidak memanggil atau menemubual anak-anak tersebut sebelum pertimbangan dan keputusan dibuat. Oleh yang demikian, kami berpuashati bahawa tindakan YA Hakim Bicara ini jelas bertentangan dengan kehendak undang-undang dan Hukum Syarak.”

[26] Berdasarkan dapatan-dapatan yang kami perolehi terhadap prosiding permohonan perintah interim hadhanah inter-parte kes Permohonan No. : 10200-038-0072-2020, kami berpuashati bahawa keputusan yang telah dikeluarkan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam tidak tepat dari segi undang-undang dan Hukum Syarak. Perkara ini secara langsung mewajarkan kami untuk campurtangan bagi mengenenpikan keputusan tersebut.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti permohonan Pemohon, kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

- 1) Permohonan semakan Pemohon adalah **DITERIMA**.
- 2) Keputusan kes Permohonan No. : 10200-038-0072-2020 bertarikh 13/11/2018 adalah **DIBATALKAN**.
- 3) Mahkamah memerintahkan supaya anak-anak di dalam kes Permohonan No. : 10200-038-0072-2020 dipanggil untuk ditemubual sebelum pertimbangan dan keputusan akhir dibuat.

Di baca dan ditandatangani oleh:-

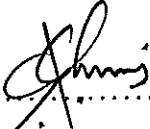
1.
YAA TN. HJ. MOHD AMRAN BIN HJ. MAT ZAIN
Pengerusi,
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

-

.....
2. **YA DATO' HJ. MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-


.....
3. **YA TN HJ. OTHMAN BIN IBRAHIM**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor